

1501015-50.2022.8.26.0618

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: João Carlos Germano

Comarca: Taubaté

Foro: Foro de Taubaté

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Autaciano Fialho dos Santos

Réu Preso

Juiz de Direito: João Carlos Germano

Vistos.

Autaciano Fialho dos Santos foi denunciado pelo Ministério Público porque, no dia 25 de julho de 2022, por volta das 8h40min, na Rua Brasilina Moreira dos Santos, nº 97, Parque Três Marias, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taubaté

Foro de Taubaté

3ª Vara Criminal

Praça Monsenhor Silva Barros - s/nº, Fórum Criminal

CEP: 12020-070 - Taubaté - SP

Telefone: (12) 2124-9113 - E-mail: taubate3cr@tjsp.jus.br

1501015-50.2022.8.26.0618 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501015-50.2022.8.26.0618

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Autaciano Fialho dos Santos

Réu Preso

Juiz de Direito: João Carlos Germano

Vistos.

Autaciano Fialho dos Santos foi denunciado pelo Ministério Público porque, no dia 25 de julho de 2022, por volta das 8h40min, na Rua Brasilina Moreira dos Santos, nº 97, Parque Três Marias, nesta cidade e comarca de Taubaté, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de tráfico, trazia

consigo e tinha em depósito, 37 pedras de crack, subproduto da cocaína, com massa líquida de 9,95 gramas.

Afirma o Ministério Público que, na manhã dos fatos, o réu levava consigo certa quantidade de entorpecentes dentro de uma sacola plástica, embaladas de forma individual, cujo destino seria a comercialização espúria.

Quando deixava sua residência, ele foi surpreendido com a presença policial, fato que fez com que ele arremessasse a sacola para dentro de sua casa e simulasse a lavagem de seu veículo.

Desconfiados da atitude suspeita, os policiais o abordaram, mas nada de ilegal foi localizado. Porém, cientes do arremesso do objeto, eles conseguiram avistá-lo atrás do portão.

No interior da sacola, localizaram 37 pedras de crack e a quantia de R\$ 418,60, proveniente do tráfico.

Indagado a respeito, o réu confessou informalmente a propriedade das drogas, razão pela qual ele foi preso e conduzido à Delegacia.

Busca, assim, a condenação do réu como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

A denúncia foi recebida às fls. 102/105.

Citado pessoalmente (fls. 115), o réu apresentou resposta escrita à acusação às fls. 119.

Designou-se audiência, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas Diego Lopes Vieira dos Santos e Tiago da Silva Pires, e procedeu-se ao interrogatório do réu, colhendo-se alegações finais do Ministério Público e da Defesa.

O Ministério Público postulou a procedência do pedido, alegando que a autoria e a materialidade do delito foram devidamente comprovadas pelas provas existentes nos autos. Afirmou que a negativa de autoria diverge do acervo probatório, sendo inútil tentativa de livrar-se da grave imputação penal. Pontuou que os autos demonstram que o réu levava consigo, em uma sacola plástica, certa quantidade de drogas, embaladas para a comercialização. Assim que saía de sua residência foi abordado pelos policiais, motivo pelo qual arremessou a sacola para dentro de casa e simulou a lavagem de seu veículo. Destacou, ainda, que a alegação de falso testemunho por parte dos policiais não prospera, discorrendo que não houve comprovação segura de arbitrariedade ou ilegalidade da diligência. Sustentou que as declarações das testemunhas merecem credibilidade e servem como fator determinante para a formação de convicção do julgador, uma vez que seus relatos foram coerentes e harmônicos, bem como estão em sintonia com os demais elementos de prova. Por fim, mencionou ser muito comum a cumulação da traficância com o uso de drogas, tendo em vista ser típico dos traficantes utilizarem de parte dos entorpecentes para uso próprio, devendo prevalecer o crime mais grave. Anotou que a quantidade de drogas apreendidas é forte indicativo de que seriam destinadas à venda, principalmente diante das circunstâncias de modo e lugar em que o crime ocorreu. Na dosimetria, na primeira fase, vislumbrou a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, em razão da natureza da droga e os maus antecedentes do réu, devendo a pena-base ser fixada acima do mínimo legal. Na segunda fase, entendeu ser aplicável a agravante da reincidência. Na terceira fase, alegou não ser possível o reconhecimento do redutor pelo tráfico privilegiado, considerando que a reincidência específica e o modo de agir demonstram que ele estava dedicado à atividade criminoso. Para o cumprimento, pleiteou a fixação de regime fechado, único compatível para punir a conduta do réu. Por fim, pediu a juntada do laudo pericial do celular e do BOPM.

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição do réu, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Preliminarmente, pleiteou a nulidade do feito, considerando a ocorrência do cerceamento de defesa, em respeito ao princípio da paridade de armas. Explicou que foi requerida a oitiva de testemunha do juízo, em razão de sua extrema importância, por ser a única testemunha ocular em favor do réu, pedido que foi indeferido. Ademais, discorreu que, ao longo da instrução, ficou devidamente esclarecido que a abordagem não foi motivada, ocorrendo com base em mera desconfiança, não sendo realizadas investigações prévias ou colhidos elementos concretos que confirmassem as suspeitas. Dessa forma, requereu o desentranhamento das provas dos autos. Por fim, defendeu que o réu afirmou, em interrogatório, que não autorizou a entrada dos policiais em sua residência. Em seus depoimentos, os policiais justificaram que entraram no imóvel porque o réu arremessou uma sacola, sem autorização de outro morador ou mandado judicial. Portanto, caracterizada a invasão de domicílio, solicitou o reconhecimento da absoluta ilegalidade da diligência policial. No mérito, enfatizou que o conjunto probatório não demonstra que os entorpecentes eram destinados à mercancia ilícita, considerando que o réu alegou serem para consumo próprio. Ressaltou, ainda, que os policiais não mencionaram terem visualizado qualquer atividade que permitisse a conclusão acerca do tráfico de entorpecente. Outrossim, sustentou que o fato de o réu ter sido preso anteriormente não serve de justificativa para embasar um decreto condenatório sem existirem provas seguras quanto a prática da conduta. Em eventual condenação, postulou a fixação da pena-base no mínimo legal, uma vez ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis. Não vislumbrou agravantes ou causas de aumento. No tocante ao regime, pediu que seja fixado o aberto, com a conversão da pena em restritiva de direitos, uma vez que o réu preenche os requisitos.

É o relatório.

Decido.

Cuida-se de ação penal pública incondicionada, por meio da qual o Ministério Público requereu a condenação do réu como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Sustenta o réu preliminares de cerceamento de defesa, ausência de justa causa para a abordagem policial e inviolabilidade de domicílio.

Por primeiro, impende ser ressaltado que não existiu o afirmado cerceamento de defesa.

A questão do indeferimento da oitiva da testemunha já foi analisada de forma exaustiva pela decisão de fls. 150/151, oportunidade em que se pontuou que a testemunha foi arrolada a destempo, de forma que a decisão atende à observância do devido processo legal, não se revelando necessário trazer novamente os argumentos lá expendidos, para os quais se remete.

Quanto às demais preliminares, com o mérito se confundem e serão apreciadas no momento adequado.

As condições da ação estão presentes, assim como os pressupostos processuais, o que rende ensejo à apreciação do mérito.

É o caso de acolhimento do pedido condenatório.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1), termo de depoimento (fls. 2/3), termo de interrogatório (fls. 4), boletim de ocorrência (fls. 5/7), auto de qualificação, vida pregressa e BIC (fls. 19), auto de exibição e apreensão (fls. 21), laudo pericial (fls. 205/208) e pelos

depoimentos colhidos em juízo.

Com relação à autoria, melhor sorte não assiste o acusado, em razão da robusta prova atribuindo a ele a prática do crime de tráfico de drogas.

A testemunha Tiago da Silva Pires, ouvida em juízo, disse que estavam em patrulhamento e visualizaram o réu com uma sacola. Esclareceu que o réu soltou a sacola quando visualizou a viatura, jogando-a no portão de sua residência. Informou que o local conhecido por ser ponto de venda de drogas. Afirmou que resolveram fazer a abordagem diante da atitude suspeita do réu. Esclareceu que tinha entorpecentes na sacola. Asseverou que não entrou na residência do réu. Não sabe informar se havia outra pessoa na residência.

A testemunha Diego Lopes Vieira dos Santos, ouvida em juízo, esclareceu que estavam em patrulhamento e visualizaram o réu próximo ao portão de sua residência. Informou que ao visualizar a viatura o réu jogou uma sacola por dentro do portão da sua residência e fingiu que estava limpando um automóvel. Asseverou que ao retornar com a viatura fizeram a verificação da sacola contendo entorpecentes. Esclareceu que pediu autorização para ingressar na residência. Informou que a esposa do réu estava dormindo na residência. Não recorda se constou no B.O.PM autorização por escrito.

O réu Autaciano Fialho dos Santos, interrogado em juízo, asseverou que tem conhecimento da acusação e negou que seja verdadeira. Informou que ele estava lavando carro na frente da sua residência. Esclareceu que não tinha drogas. Alegou que não houve autorização para entrar na residência. Asseverou que tinha 37 pedras de crack perto da sua escrivaninha de televisão, além de R\$ 420,00. Esclareceu que os fatos se deram por volta das 8 horas da manhã. Alegou que tinha junto com ele um amigo escutando rádio. Informou que tem dois filhos, trabalha como catador de recicláveis. Esclareceu que é usuário de crack e maconha. Informou que sua família sabe que ele usa droga, entretanto não consegue parar. Asseverou que os policiais não falaram nada e já foram entrando em sua residência.

Bem provadas a autoria e a materialidade.

Dispõe o artigo 33, caput, da Lei 11.343/06:

"Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa"

Dos elementos de informação colhidos no inquérito policial que se somam às provas produzidas mediante o contraditório judicial, verifica-se que a conduta do réu se enquadra no verbo trazer consigo drogas, previsto no núcleo do tipo, assim, configurada a traficância.

Com efeito, os policiais ouvidos afirmaram que logo que o réu avistou a viatura dispensou uma sacola próximo ao portão de sua casa e simulou estar lavando o carro. Arrecadaram a sacola e observaram que dentro dela havia entorpecentes.

Anoto que o fato de haver apenas o testemunho dos policiais, não serve a infirmar o teor dos depoimentos, ainda mais sem qualquer outro elemento de prova em sentido contrário.

Registro que os depoimentos prestados são coesos e harmônicos, inclusive reproduzindo, com fidelidade, o quanto afirmado no depoimento prestado na Delegacia

de Polícia, dando conta do ocorrido na data dos fatos.

A propósito da questão, pacífico nos tribunais, inclusive nos superiores, que "O depoimento de policiais é elemento idôneo à formação da convicção do magistrado quando em conformidade com as demais provas dos autos." (STJ AgRg no AREsp 262.655/SP 5ª T. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze j. 06.06.2013 DJU 14.06.2013).

Ressalto que os agentes policiais, no exercício de suas funções, são os primeiros, quando não os únicos, a travarem contato pessoal com a prática delituosa e, nessa condição, a sua interpretação sobre os fatos ocorridos reveste-se de especial importância.

Em virtude da experiência no combate à criminalidade, os policiais têm o discernimento necessário para avaliar a natureza dos acontecimentos que presenciam.

Não há razão para duvidar da palavra dos policiais que prestam serviço público de enorme utilidade à sociedade, mormente porque seus depoimentos encontram escoro nas demais provas idôneas produzidas nos autos.

O Estado credencia os policiais para o exercício da repressão criminal outorgando-lhes certa parcela do poder estatal e o Judiciário empresta essa mesma credibilidade quando chamados a prestar contas do exercício de sua função.

Assim, não há dúvida acerca dos fatos, que demandam a responsabilização do réu.

As alegações defensivas, com a devida vênia, não se mostram suficientes para afastar o decreto condenatório que se impõe no caso em exame diante das provas amealhadas.

Com relação à alegada ausência de justa causa para a abordagem policial, forçoso reconhecer que a justa causa resultou bem evidenciada.

Com efeito, os policiais foram unânimes ao afirmar que o réu dispensou uma sacola ao ver a presença da viatura.

Ora, é evidentemente suspeita a conduta de quem, ao visualizar policiais, realiza o ato de jogar algo que tinha em suas mãos, de forma a tentar se desvincular do objeto, e, portanto, plenamente justificável a abordagem policial em uma situação assim.

Acerca da questão, cabe ser registrado, por relevante, que os policiais afirmaram que realizavam patrulhamento de rotina pelo local que é conhecido pela grande incidência de tráfico de drogas.

Assim, a abordagem policial era justificada pelas circunstâncias fáticas concretas, e a suspeita era tão pertinente e fundada que resultou na apreensão do entorpecente em poder do réu.

Outrossim, impende o registro de que não havia, nas circunstâncias, meios de se fazer investigação prévia ou colher outros elementos, justamente porque o fato ensejava a pronta atuação dos policiais, especialmente no que tocava à averiguação do conteúdo da sacola.

Diante de tal quadro, e resultando a diligência em apreensão de substância entorpecente, não há que se falar em falta de justa causa para abordagem policial, cabendo o registro que o tráfico ilícito de entorpecentes é crime de natureza permanente, de forma que a posse da droga para o fim de venda enseja a prisão em flagrante do agente a qualquer tempo.

Ainda sobre a questão, cabe o registro que também alegação de violação de domicílio não se sustenta. Como se pode observar dos elementos de prova existentes nos autos, no momento da entrada os policiais afirmaram que obtiveram a anuência da mulher do réu.

Acerca desse ponto específico, como demonstra a experiência, na maioria das vezes as pessoas concedem autorização aos policiais para busca domiciliar e, quando em Juízo, alegam que não deram, tentando beneficiar o réu.

Assim, como pontuado, os policiais disseram que a mulher do réu os autorizou a ingressarem no imóvel. O fato de trazer uma declaração posterior dela não invalida o testemunho dos policiais, mesmo porque a afirmação da mulher dele em contradição com a dos policiais tem força probante maior, em razão do inegável interesse na absolvição do marido.

Nada obstante, merece registro o fato de que o encontro das drogas com o réu, na frente de sua casa, por si só validaria a entrada no imóvel, diante da situação de flagrante delito configurada.

Outrossim, nada foi encontrado dentro da casa, de forma que eventual ingresso irregular no imóvel não traria qualquer prejuízo aos autos.

De qualquer forma, não se pode olvidar que, em recente decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida há seis meses, resultou consignado que “a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado (RHC 213852, AgR, relator Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 30.5.2022).

Por fim, a alegação tanto em autodefesa como em defesa técnica, de que a droga se destinava ao uso do réu não encontra amparo nos autos.

Com efeito, a quantidade de drogas (distribuídas em 37 pedras de crack) juntamente com dinheiro, evidenciam que se destinavam não ao uso, mas, sim, à traficância, pois não é razoável admitir que uma pessoa que não tem sequer atividade lícita regular e comprovada tenha tal quantidade de droga em seu poder, ainda mais por ter sido apreendida junto com a droga quase meio salário mínimo.

Vê-se, nesse contexto, que o réu era, por ocasião dos fatos, imputável e tinha plena consciência do ilícito perpetrado, não havendo excludente de ilicitude ou de culpabilidade que viesse em seu benefício.

A prova nos autos produzida, atenta ao contraditório e à ampla defesa, é segura e não deixa dúvida de que praticou a conduta descrita na denúncia, devendo responder pelo crime em questão.

Afirmada a responsabilidade, passo à dosimetria da pena, atendendo-se à disposição do artigo 68, do Código Penal, ao critério trifásico proposto por Nélson Hungria e ao princípio da individualização da pena.

Na primeira fase impende observar a regra do artigo 42, da Lei 11.343/2006, pelo qual preponderam sobre o artigo 59 a natureza e a quantidade da substância, a personalidade e a conduta social da agente.

A qualidade da droga a despeito de significativa não pesa em desfavor do réu.

No que se refere à personalidade do agente - que no entender de Guilherme Nucci é aquela que está vinculada às qualidades morais, às distorções de caráter, à índole do sujeito, que são extraídos de sua forma habitual de ser, agir e reagir (in Individualização da pena, RT, 2005, p. 207) - se mostra negativa.

Isso porque resultou claro que o réu mentiu em Juízo quando alterou a versão dos fatos ocorridos, trazendo exposição falsa acerca de como se passaram os fatos, visando a uma injusta desclassificação, conduta que se afigura ainda mais censurável por atribuir aos policiais conduta incompatível com a regular atuação policial. Essa atitude demonstra a distorção de caráter e a ausência de senso moral por parte do réu, que se vale da mentira com o propósito de impor tumulto à instrução processual e, maliciosamente, induzir em erro o julgador, com afronta à dignidade da justiça.

Sobre a questão, oportuno ressaltar que ainda que seja o interrogatório um meio de defesa e de prova, evidente que o réu deva respeitar as limitações impostas pelas regras do processo, especialmente aquelas decorrentes da lealdade, da ética, da boa-fé, não se podendo esquecer que o processo é um instrumento para a realização da Justiça, dotado de uma série de formalidades que, em ultima ratio, são verdadeiras garantias para o réu, como também para a sociedade.

Ora, é forçoso reconhecer que o réu ao mentir deliberadamente extrapola os limites da autodefesa – que não é absoluta – demonstrando torpeza e deslealdade processual, expondo a risco a Justiça que pode, em razão de seu proceder, proferir decisão equivocada e, assim, injusta.

Afigura-se evidente que não se pode tolerar que o réu se valha de engodos, ardis e mentiras visando a escapar de uma justa condenação. O acusado que assim age, frauda a produção de provas e torna o processo uma chicana pessoal e egoísta, revelando sua personalidade dissimulada, amoral, o que justifica a elevação da pena.

Acerca do tema, pertinente o registro da lição de Andrey Borges de Mendonça (Prisão e outras Medidas Cautelares Pessoais, 2011, Método, p. 194): “Parece-nos, assim, que se o juiz constatar que o réu mentiu, poderá considerar tal circunstância no momento da pena. Não é que se esteja estimulando a confessar – até porque para isto já há uma circunstância atenuante genérica -, mas apenas negando que ao juiz e ao Poder Judiciário possa se admitir que o réu venha em juízo e, perante um agente do Estado, possa mentir livremente, como se isto fosse algo normal e aceitável, como se entende atualmente”.

O entendimento acima explicitado, ainda que minoritário na jurisprudência, tem sido prestigiado em várias decisões judiciais, cabendo o registro, por todas, de parte do judicioso voto da lavra do Desembargador José Raul Gavião de Almeida, na Apelação 00771651-20.2015, da 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, julgada em 30 de novembro de 2017 :

"...Se o réu optar por falar, no interrogatório, deverá medir suas palavras, porque elas poderão ser utilizadas também em seu desfavor. É o que ocorre na hipótese do acusado apresentar versão contrária ao convincente conjunto probatório. Identificado que faltou com a verdade, esse comportamento e o teor da inexatidão podem ser considerados pelo julgador, pois não existe direito à mentira, como não há a correspondente obrigação de ignorar a verdade".

Ainda sobre o tema, se revela oportuno registrar parte do artigo " A mentira do réu como elemento relevante na dosagem da pena", da lavra do Promotor de Justiça do Estado de São Paulo, Dr. Cleber Pereira Defina, que de forma judiciosa analisou o tema:

"...assim como a confissão dos fatos denota aspecto louvável da personalidade do agente, pois atua com boa-fé e consciência social, o inverso também é verdadeiro: a mentira do agente sinaliza aspecto censurável de sua personalidade, pois atua com má-fé e franca ausência de consciência social, constituindo-se, portanto, em dado sensível quando da individualização da pena. O indivíduo que mente à autoridade só

pretende beneficiar-se com a própria torpeza, conduz ao indesejável erro judiciário, prejudica o direito das vítimas e mina a justiça. Este cenário ratifica a deformação dos valores carregados pelo acusado pinoquista, repercutindo em necessidade ainda maior de reconstituição da tábua de valores socialmente almejada em relação ao acusado enganador. Ora, se é justo que a postura de lealdade do imputado deve surtir efeito no sentido de diminuir sua reprimenda, porque atrelada a condições favoráveis de sua personalidade, segue-se clarivamente que há mesma justiça em extrair efeito no sentido de agravar a reprimenda do réu que ostenta péssima personalidade caracterizada pela insolência de mentir perante as autoridades que colheram sua versão dos fatos, especialmente quando a este acusado lhe foi garantido o direito ao silêncio. Aliás, onde o silêncio for útil, não se justifica a mentira. O mesmo Estado que garante ao processado o direito ao silêncio, a possibilidade de não se autoincriminar, que pode criar recompensas para este falar, como é o caso da atenuante da confissão e do acordo da delação premiada, também deve poder intensificar a reprimenda daquele que ousa falar com o exclusivo propósito de enganar e promover injustiça. O embuste, tanto quanto a lealdade, é vetor a moldar a pena justa, pois ambos dizem respeito à personalidade refletida do agente"http://www.esmp.sp.gov.br/revista_esmp/index.php/RJESMPSP/article/view/148/68).

Em suma, todo acusado tem o sagrado e inafastável direito ao silêncio, que decorre da garantia democrática de que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo (*nemo tenetur se detegere* ou *privilege against self incrimination*); contudo, tal direito não pode admitir a interpretação que alguns lhe emprestam de tornar aceitável, ou pior, irrelevante, a conduta comissiva de mentir, que é vil, antiética e contrária aos valores mais comecinhos da sociedade, ao revés, deve o julgador, por ocasião da individualização da pena, caso constatado que o réu mentiu ao ser interrogado em juízo, fixar a pena-base em patamar superior ao mínimo, amparado na personalidade negativa do acusado, pois evidente a ausência de senso moral, denotando índole desviada e personalidade distorcida, daquele que podendo se calar opta deliberadamente por mentir em juízo.

Não se pode olvidar, ainda, que o réu, desde a promulgação da Lei 11.719/2008, é interrogado após a colheita de todas as provas, inclusive depoimento das testemunhas, de forma que tem plena consciência das provas produzidas e da sua repercussão, mormente em razão da defesa técnica que o assiste, razão pela qual a sua opção pela mentira se mostra ainda mais censurável, cínica e abjeta, pois abre mão do direito ao silêncio, e até mesmo da atenuante da pena da confissão, para tentar induzir em erro o juízo e assim ferir a dignidade da justiça.

A propósito, impende registrar, por relevante, que caso o julgador não aumente a pena do acusado mendaz, "estará incentivando o réu a sempre mentir, afinal, se sua mentira não lhe causa qualquer prejuízo, podendo, inclusive, livrá-lo de uma condenação justa, por que confessar um crime ou mesmo ficar em silêncio? Não punir o acusado mentiroso, aliás, viola o princípio da individualização da pena, pois equipara equivocadamente a situação do réu que fica em silêncio em seu interrogatório, com a do que mente descaradamente, em verdadeira afronta à dignidade da Justiça, pois tem o único propósito de induzir esta em erro, minando, assim, sua credibilidade perante a sociedade" ("A mentira do réu e a Dosimetria da Pena", artigo de autoria do Promotor de Justiça, Dr. André Wagner Melgaço Reis, publicado na rede mundial de computadores, no endereço <http://www.cartaforense.com.br/autor/andre-wagner-melgaco-reis/958>).

Nesse passo, cabe trazer recentíssima decisão proferida pelo voto do i. Desembargador Tetsuzo Namba:

"...demaís disso, se eles tinham a opção de confessar ou ficar em silêncio, no momento que se pronunciavam, suas palavras devem ser ponderadas, se mentem, como no

caso dos autos, isso não pode ficar sem avaliação valorativa negativa, sob pena de deixar de lado quem, muitas vezes, colabora com a Justiça e diz a verdade, seria o patrocínio indevido da "não verdade", isso mostra o caráter de alguém, flagrado no cometimento de infração penal, não se arrepende, ao contrário, faz de tudo para se livrar das imputações... (TJSP – Apelação Criminal 0001611-29.2018.8.26.0625, 8.^a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 28.11.2019).

Cabe anotar que o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, em julgamento recente, por votação unânime, decidiu no mesmo sentido da tese que ora se adota, trazendo excertos de decisão proferida por este juízo como razão de decidir, como se infere dos autos da Apelação nº 0000129-67.2018.8.26.0618, de relatoria do ilustre Desembargador Roberto Porto:

“Ademais, como bem destacou o Ministério Público a fl. 277 o fato de o réu ter mentido em Juízo, trazendo aos autos fatos absolutamente inverídicos, revela sua personalidade desvirtuada, devendo ser considerado no momento da exasperação da reprimenda. Aliás o Douto Magistrado bem fundamentou a exasperação da pena-base...”

No mesmo sentido já decidiu a Colenda 14^a Câmara de Direito Criminal, por votação unânime nos autos da apelação nº 0000640-36.2016.8.26.0618, de relatoria do ilustre Desembargador Walter da Silva:

"(...) Em relação ao delito previsto no artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/03: Sopesadas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, a pena base foi bem fixada acima do mínimo legal, fundamentando o douto Magistrado na personalidade negativa do apelante, pois demonstrou perante o Juiz desonestidade e insinceridade, o que revelou a distorção de caráter, e assim a reprimenda foi tornada definitiva na ausência de outras causas modificadoras."

Ainda sobre a mentira do réu como circunstância desfavorável, com enfoque na personalidade desviada, em voto proferido pela 6.^a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, pela voz do ilustre relator Zorzi Rocha, assentou:

“Dessa forma, se o réu mentir em seu interrogatório, negando a prática do crime por ele cometido, ou explicando o crime ao apresentar uma versão fantasiosa do fato, tudo a fim de se obter uma injusta absolvição, justificado está o aumento de sua pena-base com fundamento na personalidade negativa. Afinal, a insinceridade e a desonestidade demonstradas perante o Juiz – como explanado no item 2 suso exposto – revelam distorção de caráter e ausência de sendo moral por parte do Réu, que se utilizou da mentira – subterfúgio repugnado pela ética e pelo dever de lealdade – com nítido propósito de tumultuar a instrução processual e induzir em erro o julgador, afrontando, assim, a dignidade da Justiça” (TJSP – Apelação Criminal 0001317-32.2017.8.26.0618, j. 3.10.2019).

Não outra a conclusão a que chegou o ilustre Des. Ricardo Sale Júnior, chamando atenção para a correção do decisum que elevou a pena-base pelo fato de haver o réu mentido ao ser interrogado em juízo “fato que evidencia uma personalidade voltada para o crime” (TJSP – Apelação Criminal 0002205-19.2013.8.26.0625, 15.^a Câmara de Direito Criminal, j. em 8.8.2019).

No mesmo sentido o voto da lavra do ilustre Des. Tetsuo Namba, ao aduzir correta a sentença que reconheceu a mentira do réu como personalidade deturpada, justificando-se a elevação da pena na primeira fase da dosimetria. (TJSP – Apelação Criminal 0001091-27.2017.8.26.0618, 8.^a Câmara de Direito Criminal, j. em 5.12.2019).

Também em processo que teve trâmite por esta 3.^a Vara, em sede de apelação (Apelação Criminal nº 0000037-05.2017.8.26.0625), a i. Desembargadora Ivana David,

assentiu com a tese ora perfilada, nos termos seguintes, fazendo alusão, em parte, à decisão proferida nos autos do Processo Criminal nº 0003339-30.2014.8.26.0372, 1ª Vara Judicial de Hortolândia - Juiz de Direito, Luis Mário Mori Domingues j. 21.01.2015.

“E escorreita a majoração praticada, uma vez que ao mentir em juízo, a acusada foi muito além do seu direito ao silêncio, mentindo para a Justiça, tentando se esquivar das consequências dos seus atos, porquanto, “nosso ordenamento jurídico, amparado por tratados internacionais e na linha de todos os demais sistemas penais do mundo garantem ao acusado o direito ao silêncio. Significa dizer que o réu, silenciando-se, não pode ser acusado com base nesse fundamento, isto é, ausente provas contra o réu, ele não pode ser condenado porque ficou em silêncio. Em momento algum o direito ao silêncio confunde-se com direito a mentira. O silêncio é uma conduta passiva, fundada no direito de não produção de prova contra si. A mentira é conduta ativa, é a produção de prova falsa em juízo”, demonstrando, com isso, além da má índole, que o crime não constituiu um episódio accidental em sua vida. (Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 10.12.2019).

Em outro processo que teve trâmite por esta Vara (1501572-71.2021), bem concluiu o Ilustre Desembargador Zorzi Rocha:

“A pena-base foi fixada em 1/6 (um sexto) acima do patamar mínimo, com fundamento no artigo 59 do Código Penal, destacada a rubrica da personalidade desregrada do Réu o qual modificou a realidade dos fatos com o nítido intuito de minimizar os efeitos de sua conduta, dificultar a análise da prova e criar a ideia de irregularidade da conduta policial. Não se trata de mera mentira narrada em Juízo, mas da criação de realidade diversa (disse que era tatuador e tinha um estúdio de tatuagem), com a produção de prova testemunhal nesse sentido (a testemunha João Pedro disse em Juízo que foi tatuado pelo Réu, embora nunca tivesse visto seu estúdio/oficina). Destaque-se que o próprio Réu confirmou informalmente que produzia armas artesanais, fornecendo detalhes de como eram feitas a produção e a usinagem, sendo essa narrativa judicial conduta que realmente extrapolou os limites da autodefesa, podendo ser utilizada de forma regular e como aqui ocorreu para exasperação da pena-base.” (Apelação Criminal, j. em 26.5.2022).

No que respeita à culpabilidade, o que se vê é natural à espécie.

O réu possui maus antecedentes pelos processos 27089-83.2011, da 1.ª Vara Criminal de Taubaté, e 3008-12.2007, desta 3.ª Vara Criminal de Taubaté, sendo reincidente pelo processo 10517-03.2015, também desta 3.ª Vara.

Acerca da conduta social do réu não há elementos para que se proceda à sua valoração.

Quanto aos motivos do crime e as circunstâncias, nada há de relevante.

O sujeito passivo do tráfico de drogas é a coletividade, titular do bem jurídico a saúde pública, não havendo, assim, falar-se em comportamento da vítima.

Diante da personalidade negativa e dos maus antecedentes, elevo a pena mínima cominada em abstrato em 1/3, alçando-a a 6 anos e 8 meses de reclusão, além de 666 dias-multa.

Na segunda fase, não há circunstância atenuante. Vislumbro, contudo, a agravante da reincidência pelo processo 10517-03.2015, também desta 3.ª Vara, que faz elevar a pena em 1/6, alçando-a a 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, além de 777 dias-multa.

Na terceira etapa, ausentes causa de diminuição ou aumento, fixo a pena,

definitivamente, em 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, além de 777 dias-multa.

O regime inicial de cumprimento, sendo desfavoráveis as circunstâncias judiciais e reincidente o réu, será o fechado.

Anoto que essa é a posição pacificada no Superior Tribunal de Justiça, que determina o regime fechado ao condenado com circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidente (RECURSO ESPECIAL Nº 1.710.041 - MS).

Ainda, da mesma Corte Superior:

"1- Nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, bem como a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do Código Penal). 2 - Constatada a reincidência do paciente e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, é forçoso reconhecer a possibilidade de manutenção do regime fechado para o cumprimento da pena, não havendo que se falar, na hipótese, em incidência do enunciado 269 da Súmula desta Corte, segundo o qual "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais". 3 - No caso em análise, embora o quantum da reprimenda (1 ano e 6 meses de reclusão) comporte o regime aberto, a reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente impedem, inclusive, a fixação do regime intermediário, sendo adequada a imposição do regime fechado. 4 - Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no HC 407.838/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe de 21/11/2017).

Nos termos do artigo 49, §1.º, do Código Penal, o valor do dia multa será de 1/30 avos do salário mínimo praticado à época do delito, pois ausentes elementos para aferição da capacidade financeira do réu, devendo ser atualizado pelos índices de correção monetária da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde aquela data até o efetivo pagamento.

Observo que o réu não preenche os requisitos do artigo 44, do Código Penal, pois é reincidente e as circunstâncias judiciais não indicam ser suficiente a substituição por pena restritiva de direitos.

Também não preenche o réu os requisitos do artigo 77, do Código Penal, especialmente pela reincidência, sendo inviável a suspensão condicional da pena.

Deixo de fixar indenização mínima prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, pois inexistente pedido nos autos, fato que inviabiliza o contraditório e a ampla defesa, bem como se afasta do princípio da congruência.

Mantenho a prisão, recomendando-se aquela em que se encontra.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal que inexistente ilegalidade em vedar ao condenado recorrer em liberdade quando esteve preso cautelarmente durante toda instrução criminal, desde que permaneçam os motivos dessa segregação (STF, HC n. 89824/MS 1ª T. unânime Min. Carlos Ayres Britto DJe 28/8/2008; STF HC n. 114536/MG 2ª T. unânime Rel. Min. Ricardo Lewandowski DJe 4/12/2012; STJ, HC n. 222002/RJ 5ª T. unânime Rel. Min. Laurita Vaz DJe 11/10/2013).

No caso concreto, o réu permaneceu preso cautelarmente durante todo o processo e o retorno ao convívio social, neste momento, é inoportuno. Assim, para que a ordem pública permaneça acautelada, é necessária a manutenção do cárcere.

O histórico criminal do réu indica que faz da prática de infrações penais meio de

vida, mostrando-se imprescindível acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça. A reiteração criminosa evidencia o envolvimento com o mundo do crime, de forma que apenas a prisão preventiva se mostra suficiente para afastar a possibilidade de novas infrações penais.

Nesse contexto, ainda persistem os fundamentos fáticos e jurídicos que ensejaram a segregação cautelar, agora mantida com base em um juízo de certeza da culpa.

Assim, presentes os pressupostos e fundamentos para a decretação da prisão preventiva, a teor do artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal, fica mantida a prisão (artigo 387, §1º, do Código de Processo Penal), negando-se o direito de recorrer em liberdade.

Diante de tal quadro, verificada a necessidade da manutenção da custódia cautelar, resulta cumprido o disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Não há dados suficientes para realização da detração da pena, razão pela qual deixo de cumprir o disposto no artigo 387, §2, do Código de Processo Penal, cabendo ao juízo da execução, que detém as informações necessárias, analisar oportunamente eventual direito por conta do período de prisão cautelar, consoante determina o artigo 66, inciso III, alíneas "b" e "c". Nesse sentido: (HC 169.072/SP, relator Ministro Og Fernandes – 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, julgado em 10.6.2010).

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, de acordo com o artigo 804, do Código de Processo Penal.

Posto isso, acolho o pedido formulado na denúncia para o fim de condenar o réu Autaciano Fialho dos Santos à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, além de 777 dias-multa, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, iniciando-se o cumprimento em regime fechado, recomendando-o à prisão em que se encontra, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, condenando-o, outrossim, ao pagamento das custas no importe de 100 UFESPs, nos termos do artigo 4.º, § 9.º, alínea "a", da Lei estadual 11.608/03.

Após o trânsito em julgado deverá a Serventia levar a efeito as seguintes providências:

- a) intimar o réu para proceder ao recolhimento da taxa judiciária;
- b) oficiar ao TRE para cumprimento do disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal;
- c) oficiar ao IIRGD comunicando a condenação do réu;
- d) expedir guia de execução penal.

R.P.I.

Taubaté, 8 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA